

1501702-76.2022.8.26.0537

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... - ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE DROGAS. O tipo penal previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343 /2006 é subsidiário em relação ao 33, de modo que a posse ou guarda de instrumentos destinados à fabricação de drogas, uma vez praticadas no mesmo contexto fático do tráfico e com a finalidade de comercialização do entorpecente produzido, constituem atos preparatórios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501702-76.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501702-76.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217999/2022 - 4º Distrito Policial de Diadema, EU6405/2022 - 4º

Distrito Policial de Diadema, 2217999 - 04º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCILEIA DE SOUZA LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

LUCILEIA DE SOUZA LIMA e FABIO GORDIJO AMERICO, qualificados nos autos, foram denunciados, em concurso material, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, 34 e 35, caput, da Lei no 11.343/06, porque, conforme a denúncia, desde data incerta até o dia 10 de agosto de 2022, por volta das 14h30min, os acusados, associaram-se com outros indivíduos até o momento não identificados e entre si para praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da lei retro-mencionada. Ademais, no dia 10 de agosto de 2022, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 650 (seiscentas e cinquenta) porções individualizadas de cocaína em pó, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica. O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 157-159. Além disso, também no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 14h30min, possuíam, em concurso e unidade de desígnios, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu FÁBIO GORDIJO AMÉRICO foi regularmente notificado (fls. 101), apresentou defesa prévia a fls. 105-107, a denúncia foi recebida a fls. 111-112 e foi citado a fls. 189. A ré LUCILEIA DE SOUZA LIMA foi regularmente notificada a fls. 137, apresentou defesa preliminar a fls. 173-174, a denúncia foi recebida a fls. 175-176 e foi citada a fls. 197.

Na audiência de instrução debates e julgamento foi colhida a prova oral.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais. A manifestação ministerial foi transcrita no termo de audiência, enquanto a manifestação da defesa foi realizada de forma oral, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, não verifico situação de nulidade das provas por suposta ilegalidade na atuação dos policiais. Como se sabe, nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso dos autos, entendo que tais requisitos legais foram cumpridos.

Com efeito, no caso dos autos, após o recebimento de denúncia anônima, indicando que os réus embalavam porções de cocaína para abastecimento da "cracolândia" em São Paulo, policiais civis, em viatura descaracterizada, diligenciaram até o endereço indicado na notitia criminis apócrifa, visualizaram o réu FÁBIO e, após breve acompanhamento, necessário para estabelecer a fundada suspeita, abordaram-o e encontraram 300 invólucros de cocaína embalados em saco plástico. Não se trata, portanto, de hipótese de busca pessoal realizada de forma aleatória e indiscriminada em pessoas escolhidas a esmo em via pública, mas abordagem de pessoa em atitude suspeita, após observação de campo realizada a partir de denúncia anônima.

Não há que se falar, ainda, em nulidade pelo ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial. É que no bojo do inquérito, os policiais civis consignaram que o réu franqueou acesso ao seu domicílio. Em juízo, reforçaram essa manifestação, o que foi confirmado pela corrê LUCILEIA, que reconheceu ter franqueado a entrada dos agentes.

De qualquer forma, denota-se que na ocasião em que os policiais ingressaram na residência dos réus, FÁBIO encontrava-se em evidente situação flagrancial (eis que foram encontradas drogas em sua posse), tanto é que referidos indícios se confirmaram com a localização de entorpecentes e petrechos, razão pela qual os agentes públicos estavam autorizados a ingressar no local.

A cláusula constitucional da inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta, pois o inciso XI do artigo 5.º da Constituição Federal preconiza que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito".

A Colenda Suprema Corte, em r. decisão da lavra do e. Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do RE 1342077/SP, reafirmou a tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar: O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

Na mesma r. decisão, o e. Ministro Alexandre de Moraes anulou o v. acórdão do STJ (HC 598.051-SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz) que exigia consentimento do morador comprovado por documentação escrita da diligência policial e gravação audiovisual, porque tais exigências consubstanciam inovação em matéria constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei e que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

A propósito, não se pode olvidar do entendimento jurisprudencial no sentido de que,

em caso de crimes permanentes (como no caso dos autos), prescindível mandado de busca e apreensão em razão da situação de flagrante: HC 309.554/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 27/03/2015.

Logo, considerando (i) que os policiais já estavam em diligência para apurar informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes pelos réus; (ii) que em busca pessoal foi encontrada, na posse de FÁBIO, a elevada quantia de 300 invólucros de cocaína embalados em saco plástico; (iii) que após a busca pessoal, segundo os agentes policiais, o próprio réu admitiu que mantinha drogas e maquinários na residência onde morava com LUCILEIA, e que lá mantinha maquinário para o tráfico e invólucros vazios para separação de drogas (fls. 16); (iv) que LUCILEIA admitiu ter franqueado o ingresso dos policiais, afastando a nulidade/ilicitude em apreço.

Pelo mérito a presente ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, impondo-se: (i) a condenação do acusado FÁBIO pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas, (ii) o reconhecimento da absorção/consunção do crime do art. 34 pelo crime do art. 33 (eis que praticados em um mesmo contexto fático), (iii) a ausência de provas suficientes acerca da estabilidade e permanência a caracterizar o crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n.º 11.343/2006), e (iv) a absolvição de LUCILEIA em relação a todos os delitos a ela imputados, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito previsto no art. 33 restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 157-159, que atestou positivo para a entorpecente cocaína, substância esta considerada ilícita pela Portaria 344/1998 SVS/MS. Consigno que a perícia não foi contestada pela defesa.

A autoria, no que tange ao réu FÁBIO GORDIJO AMÉRICO, também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo.

É certo que de acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Em juízo, a testemunha Décio Pinto Cortez afirmou que no dia anterior recebera informação de que na residência do casal estavam sendo armazenadas drogas, para entregas. A informação indicava que no dia seguinte seria feita a entrega das drogas. Disse que na data indicada então os policiais fizeram campana, e visualizaram o acusado Fábio saindo da residência, e saindo em direção à rua principal. Os policiais conseguiram abordar o acusado Fábio, e com ele havia 300 porções de droga. Ele então admitiu estar praticando o tráfico de entorpecentes, e indicou que em sua casa havia mais drogas e maquinários. Afirmou que foi até a residência do réu, que franqueou a entrada dos policiais. No local, os policiais encontraram mais drogas e maquinários. A ré estava no quarto, juntamente com os equipamentos. Questionado, disse que a denúncia anônima indicava que o réu era o responsável por embalar e entregar as drogas, e a ré seria a responsável pela negociação das substâncias entorpecentes. A ré foi questionada no interior da residência, e em princípio negou a participação, mostrando-se surpresa. Afirmou que posteriormente, a ré admitiu que no local havia maquinários, os quais seriam de seu esposo (o acusado). Foi encontrado um "pó branco" no local que, segundo a ré, era utilizado para "batizar" a droga. Afirmou que a ré não admitiu participação no tráfico, apenas indicando que sabia que na residência havia maquinários e drogas, e que a responsabilidade destas era de seu esposo. Confirmou que havia no imóvel mais um "rapazinho", uma "mocinha" e crianças pequenas. O local é um "sobradinho". Na entrada há uma garagem, uma sala e uma cozinha. Na parte de cima havia alguns cômodos, e em um dos quartos estavam os equipamentos e maquinários. Reiterou que o acusado Fábio admitiu a traficância, e que Lucileia negou participação no delito, embora tenha admitido ter ciência das drogas e maquinários mantidos no interior da residência. Questionado, disse que a participação de Lucileia no delito foi indicada pela denúncia anônima, mas a partir desta não foram realizadas outras diligências para apurar sua veracidade quanto à conduta da corré, eis que os

policiais não tiveram acesso às mensagens de aplicativo de celular.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rafael dos Reis Silva que, ouvido em juízo, confirmou integralmente o relato contido na denúncia.

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo por estes policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, sobretudo porque seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP – STF).

Deve-se ressaltar que o réu FÁBIO GORDIJO AMÉRICO e a ré LUCILEIA DE SOUZA LIMA, permaneceram em silêncio na instrução policial (fls. 11 e 12) .

Em juízo o acusado FÁBIO admitiu ter recebido as drogas e os equipamentos de um conhecido (de prenome Alex), para mantê-los em depósito em sua residência por alguns dias, mediante a promessa de receber R\$ 500,00. Disse que, por estar passando por dificuldades financeiras, aceitou a proposta. Negou que quando foi abordado pelos policiais estivesse na posse de entorpecentes. Não mexeu nas sacolas, mas sabia que se tratava de drogas. As drogas e equipamentos estavam em sua casa, e LUCILEIA, sua companheira, não sabia. Disse estar arrependido.

LUCILEIA, por sua vez, disse que havia se separado de FÁBIO, e que haviam retomado o relacionamento havia poucos dias. Disse que não sabia que FÁBIO mantinha em depósito os equipamentos e as drogas. Negou participação no tráfico. Disse ter franqueado o ingresso dos policiais na residência.

Ora, nos termos do art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso dos autos, a forma como estava embalada a droga, a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, o encontro de dinheiro, a ocorrência de denúncia anônima e o resultado da observação prévia feita pelos policiais são indicativos do intuito de traficância. Por outro lado, pela própria quantidade e demais circunstâncias, não há como desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistirem pacificamente em uma única pessoa.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira “lei do silêncio”, por temer sofrer represálias.

Assim, não há dúvidas de que o comportamento do réu FÁBIO se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1.ª T. – HC n.º 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p. 11.012).

No entanto, não é possível concluir, com a certeza necessária à condenação, que a ré LUCILEIA DE SOUZA LIMA, dolosamente, praticasse alguma das condutas do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Contra a acusada, de concreto, existe nos autos apenas a denúncia anônima, fato este absolutamente insuficiente para juízo condenatório. Não houve o necessário aprofundamento das investigações a partir da denúncia anônima, mas apenas uma única diligência para a apreensão das drogas e maquinários. Além disso, contra ela não houve campana policial ou busca pessoal. Em interrogatório judicial, a ré, inclusive, confirmou o que narrou na ocasião do flagrante (fls. 34), afirmando não ter qualquer participação no crime, sendo FÁBIO o único responsável.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça no HC 566.565-SP decidiu que o simples fato de relacionamento marital, doméstico ou de qualquer outra natureza afetiva não enseja a presunção de que a companheira sabia da conduta ilícita realizada pelo seu companheiro, mesmo que os atos sejam praticados na residência do casal. O fato de, eventualmente, LUCILEIA saber de condutas ilícitas praticadas por FÁBIO não a torna coautora do delito. Nesse sentido, há apenas meras presunções em desfavor de LUCILEIA, impondo-se a sua necessária absolvição.

Por conseguinte, tampouco restou demonstrado o crime de associação para o tráfico. Afinal, para que se caracterize o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é essencial que seja comprovada a estável e duradoura associação entre os denunciados (ou entre estes e terceiros), não bastando a mera condição de esposa ou companheira para fins de enquadramento, conforme asseverou o Supremo Tribunal Federal no HC 183.361-SP. Ressalto, mais uma vez, que a partir da denúncia anônima recebida não houve aprofundamento das investigações para apurar vínculos de estabilidade e permanência, de modo que a versão do acusado FÁBIO, de que praticara o delito de forma pontual e circunstancial (e não de forma estável e permanente) não restou infirmada pelos demais elementos de convicção.

Com relação ao delito do art. 34, da Lei de Drogas, como já afirmado, é necessário incidir o princípio da consunção, consoante entendimento amplamente majoritário dos Tribunais Superiores. Entendo que, no caso concreto, o tipo penal previsto no art. 34 da Lei de Drogas foi subsidiário em relação ao art. 33, pois as condutas imputadas ao denunciado destinavam-se precipuamente a um só crime-fim: o tráfico de entorpecentes, não ficando caracterizada a existência de contextos autônomos aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado - a saúde pública - de forma distinta, o que vergasta a pretensão ministerial de concurso material entre os delitos retromencionados. A propósito:

CONSUNÇÃO – ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS. O tipo penal previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343 /2006 é subsidiário em relação ao 33, de modo que a posse ou guarda de instrumentos destinados à fabricação de drogas, uma vez praticadas no mesmo contexto fático do tráfico e com a finalidade de comercialização do entorpecente produzido, constituem atos preparatórios do crime-fim mais grave, razão pela qual hão de ser por este absorvidas, observado o princípio da consunção. (...) (STF – HC 170640/SP – Primeira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio – Julgamento 11/02/2020 – Publicação 07/04/2020).

De qualquer forma, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, a localização de equipamentos e petrechos utilizados para a prática do delito será considerada para fins de dosimetria, como circunstância desfavorável do crime de tráfico de entorpecentes.

Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade.

Ressalto que o argumento de que o acusado praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão.

Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu: “Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar e

lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

É o que basta para a caracterização do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33, da Lei n.º 11.343/2006, em relação ao acusado FÁBIO.

Passo à dosimetria da pena, inicialmente, de FÁBIO GORDIJO AMÉRICO no que se refere ao delito previsto no art. 33.

Na primeira fase da dosimetria, seguindo os critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, deve ser considerada como circunstância judicial preponderante desfavorável a localização e apreensão de petrechos e equipamentos destinados ao tráfico (por força do princípio da consunção), bem como a natureza das drogas apreendidas, dentre elas a cocaína, substância que notoriamente vulnera de forma mais intensa o bem jurídico protegido – qual seja, a saúde pública –, causando maior grau de dependência do que outras drogas ilícitas, como a maconha. Anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286, grifei). Significa dizer que o legislador explicitou, no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que já deveriam ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59, do Código Penal, transformando-as em preponderantes.

Por outro lado, o acusado ostenta uma condenação definitiva, sem efeito de reincidência, porquanto já ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos (processo n.º 0037319-05.2003.8.26.0161, pena cumprida em 09 de agosto de 2007, fls. 40-41 ). Referida condenação pode ser usada para fins de reconhecimento de maus antecedentes. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG. 20-11-2020 PUBLIC. 23-11-2020, grifei).

Diante disto, elevo a pena base em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, embora parcial (pois o réu negou que estivesse na posse direta de drogas no momento em que fora abordado pelos policiais) considero eficaz a confissão efetuada pelo réu (utilizada como fundamento para condenação, nos termos da Súmula n.º 545, do E. Superior Tribunal de Justiça). Em razão disso, aplico a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP e reduzo as penas em 1/6. Obtenho, assim, as penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não vislumbro a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006. Isto porque, para incidência do referido dispositivo legal, é necessário o concurso simultâneo

de quatro circunstâncias, quais sejam: (i) que o agente seja primário, (ii) de bons antecedentes, (iii) não se dedique às atividades criminosas e (iv) nem integre organização criminosa. Ora, no caso dos autos, a elevada quantia de drogas e a presença de maus antecedentes afasta a possibilidade da causa de diminuição em comento.

Assim, torno definitiva a pena supracitada, de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Considerando a quantidade de pena estabelecida e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (consoante fundamentação acima), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, observados os termos do art. 33, § 3.º, do CP. Consigno que à vista das especificidades do caso concreto, considerando a diversidade das drogas e a traficância de substâncias que causam uma maior dependência química, a fixação de regime inicial diverso não seria suficiente para a reprovação e prevenção da conduta. Ademais, a fixação deste regime inicial não fere o disposto no art. 33, § 3.º, que estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal. Ocorre que conforme fundamentação acima, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, a despeito de estarem evidenciadas no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006 como preponderantes, também são circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59, do Código Penal.

No que se refere à aplicação do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, verifico que diante da quantidade de pena estabelecida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso, ainda que considerado o tempo da prisão preventiva. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: “A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena” (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei).

De fato, raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o juízo das execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese os termos da Resolução n.º 05, do Senado Federal, não estão presentes os requisitos autorizadores à substituição da pena por restritiva de direitos, notadamente pela quantidade de pena estabelecida.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de:

(a) CONDENAR o réu FÁBIO GORDIJO AMÉRICO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006;

(b) ABSOLVER o réu FÁBIO GORDIJO AMÉRICO da prática prevista no art. 34, caput, da Lei n.º 11.343/2006, reconhecendo o princípio da consunção e a inoccorrência de crime autônomo, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

(c) ABSOLVER o réu FÁBIO GORDIJO AMÉRICO da prática prevista no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(d) ABSOLVER a ré LUCILEIA DE SOUZA LIMA da prática de todos os crimes a ela

imputados pela denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Mantenho a prisão preventiva do acusado FÁBIO GORDIJO AMÉRICO. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. Por tal razão, mantenho a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos das decisões proferidas nestes autos, adotando-as como razão de decidir. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Condene o sentenciado FÁBIO ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária.

Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006. Decreto a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que o réu condenado possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado:

- a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- b) oficie-se ao IIRGD;
- c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

Não havendo interesse na preservação dos objetos apreendido (auto de apreensão de fl. 28/29), e considerando a ausência de valor econômico, autorizo sua destruição. Em relação a LUCILEIA, oportunamente arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Diadema, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA